

1005187-30.2019.8.26.0220

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Maricy Maraldi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 10ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... 'o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

10ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1005187-30.2019.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005187-30.2019.8.26.0220

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Anulação de Débito Fiscal

Impetrante:

Posto Três Garças Ltda

Litisconsorte Passivo e Impetrado:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maricy Maraldi

Vistos.

POSTO TRÊS GARÇAS LTDA., qualificada nos autos, impetrou o presente Mandado de Segurança, sem pedido de liminar, em face do SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (vinculado à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO), aduzindo, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída sob a forma de sociedade limitada, possuindo como objeto social prestação de serviços de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Afirma que no regular exercício de suas atividades, encontra-se sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, em virtude do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, do artigo 1º da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1.989, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2.000, nas faturas de energia elétrica. Sustenta que se tratar de consumidora de energia elétrica em grande escala, firmou com a empresa concessionária energia "contrato de demanda reservada ou potência de energia elétrica", porém, a autoridade impetrada vem incluindo na base de cálculo do ICMS a demanda contratada e não a demanda efetivamente consumida pela impetrante, em afronta ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal, bem como, ao entendimento fixado na Súmula 391 do STJ. Assim, requereu a concessão da segurança para que seja determinada a exclusão da conta de luz da impetrante do valor referente ao ICMS que incide sobre a reserva de demanda de energia elétrica não utilizada, e para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança, determinando-se que a autoridade coatora abstenha-se de tal cobrança e que o valor pago a mais seja

retirado, definitivamente, nas próximas faturas de consumo de energia elétrica; a declaração e autorização do direito de compensar o ICMS recolhido indevidamente, nos últimos cinco anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da presente impetração e no período posterior a propositura do presente writ, em respeito ao disposto no artigo 168 do Código Tributário Nacional – CTN, cujos valores deverão ser acrescidos de juros equivalentes à taxa SELIC, calculados a partir da data do pagamento a maior; sendo atribuído à causa o valor de R\$ 1.000,00 (fls. 20).

Com a inicial, vieram procuração e os documentos de fls. 21/440.

Determinou-se a notificação da autoridade impetrada para informações (fls. 455/456).

A Fazenda do Estado de São Paulo requereu seu ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial às fls. 466.

Notificada, a autoridade coatora apresentou as informações de fls. 472/492 aduzindo, preliminarmente, a não demonstração da causa de pedir, a inadequação do pedido de natureza declaratória em sede mandamental, a impossibilidade de obtenção de benefício econômico relativo a período pretérito, a ilegitimidade ativa da impetrante. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança, sustentando a improcedência do pedido, ao argumento de que a impetrante parte de premissa equivocada, pois afirma que está recolhendo ICMS sobre energia elétrica que não consumiu, quando na realidade, a energia elétrica que está sendo cobrada da impetrante foi-lhe integralmente fornecida, salientando que a demanda contratada não é energia elétrica posta à disposição da contratante, mas sim, fornecida, e como tal, legitimamente cobrada. Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

O Ministério Público não apresentou parecer de mérito (fls. 495/497).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO. DECIDO.

Defiro o ingresso da Fazenda do Estado de São Paulo como assistente litisconsorcial da autoridade coatora. Anote-se.

Trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante, pessoa jurídica de direito privado, e consumidora de energia elétrica em grande escala, objetiva afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda reservada de potência contratada e não utilizada, excluindo-na da base de cálculo do imposto, por entender que a incidência deve ocorrer apenas sobre a demanda de potência efetivamente utilizada, e não sobre a energia elétrica que não consumiu, bem como pretende a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos 05 (cinco) anos e no período posterior a propositura do presente writ.

A alegação da impetrante de que a autoridade impetrada está embutindo no valor da cobrança do ICMS a energia elétrica que não consumiu, baseada exclusivamente no contrato de demanda reservada ou de potência de energia elétrica, por si só é suficiente para revelar o seu interesse de agir da impetrante a adequação da via eleita.

Rejeito, também, a preliminar de inadequação de pedido de natureza declaratória.

Contrariamente ao alegado pela autoridade impetrada, a pretensão da impetrante não se limita a declaração de inexistência de relação jurídico tributária, mas sim, insurge-se a impetrante em razão do fato de estar arcando com o pagamento de ICMS embutido na conta de fornecimento de energia elétrica, decorrente de contrato de reserva de demanda ou potência, base de cálculo que considera equivocada, na medida

em que está pagando por energia que não consumiu efetivamente.

Enfim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que a impetrante é consumidora final de energia elétrica e suportou o ônus financeiro do ICMS incidente sobre a demanda contratada, como comprovam as faturas e notas fiscais colacionadas e que instruem a inicial, o que a caracteriza como contribuinte "de fato" do imposto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já firmou o entendimento no sentido da legitimidade ativa do consumidor de energia elétrica, na condição de contribuinte de fato, para discutir em juízo a incidência do ICMS no fornecimento de energia elétrica sobre a demanda contratada e não utilizada. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica aos casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil." (REsp 1299303/SC, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, j. 08/08/2012).

A preliminar de impossibilidade de obtenção de benefício econômico relativo a período pretérito, confunde-se com o mérito, e como tal será apreciada.

No mérito, de rigor a concessão parcial da segurança.

Trata-se na presente de mandado de segurança no qual a impetrante objetiva o reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS, com o qual vem arcando, sobre o fornecimento de energia elétrica no "contrato de reserva de demanda ou potência", devendo a cobrança ficar adstrita apenas a energia que foi consumida e integralmente fornecida e não sobre a reservada.

Em que pesem as razões da autoridade impetrada e da Fazenda do Estado, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante julgamento afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 63, REsp 960.476/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.03.2009), que firmou entendimento no sentido de que "a simples formalização de contrato de fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria, razão por que não pode o ICMS incidir sobre a denominada "demanda contratada". O tributo incide apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor.

Nesse sentido Recurso Especial nº 343.952/MG, REL. MIN. ELIANA CALMON, j. 05.02.2002; Recurso Especial nº 647.553/ES, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, j. 05.04.2005; e Recurso Especial nº 960.476/SC, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 11.03.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. Transcrevemos:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que 'o ICMS não é

imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa'. 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que 'não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência'. Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08." Estes julgados do Superior Tribunal de Justiça resultaram na Súmula 391, segundo a qual "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ICMS. CRITÉRIO DE DEMANDA RESERVADA OU CONTRATADA. TRIBUTO QUE SOMENTE INCIDE SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. I - Quedou-se o recorrente agravante em afirmar, genericamente, ter a Corte ordinária deixado de se pronunciar sobre dispositivos legais, sem demonstrar por que esta análise seria imprescindível à solução da controvérsia, de modo a viabilizar, ao menos em tese, outro resultado ao julgamento. Assim sendo, evidente incidir a Súmula n. 284/STF, a inviabilizar o especial, no particular. II - Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "o fato gerador do ICMS dá-se com a efetiva saída do bem do estabelecimento produtor, a qual não é presumida por contrato em que se estabelece uma demanda junto à fornecedora de energia elétrica, sem a sua efetiva utilização" (REsp nº 825.350/MT, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 26.05.2006, p. 250). III - Outro precedente citado: REsp nº 806.281/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 11.05.2006, p. 171. IV - Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no REsp nº 855.929/SC Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO 1ª Turma Data do Julgamento: 19.09.2006 grifamos).

Depreende-se do acima exposto ser inexigível a incidência de ICMS sobre o valor contratual da demanda reservada de energia elétrica.

Com relação ao pedido de compensação tributária com cobranças futuras, o pleito não pode prosperar, isto pois, a impetrante utiliza-se da via mandamental como substitutiva de ação de cobrança, sendo inadequada a via eleita, para a cobrança das parcelas pretéritas e compensação com as futuras.

Com efeito sumulou-se o entendimento no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas 269 e 271 do STF).

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Com relação ao pedido de compensação dos valores recolhidos a maior, em razão da impetrada ter ilegalmente embutido na cobrança do ICMS energia elétrica não consumida ou efetivamente utilizada, em futuras cobranças a pretensão não procede, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a compensação de crédito tributário, nos termos dos artigos 156, II, e 170 do CTN, somente é possível nos casos em que haja lei específica autorizando.

E sob tal aspecto, no Estado de São Paulo inexistente lei que autorize a compensação de débitos tributários com créditos contra a Fazenda do Estado e suas autarquias, com lastro em títulos judiciais, o que impede a compensação pretendida.

Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e o faço, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, e por conseguinte, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança para reconhecer e declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica não utilizada, devendo a autoridade impetrada abster-se de tal cobrança e que o valor pago a mais seja retirado, definitivamente, nas próximas faturas de consumo de energia elétrica.

Custas na forma da lei, descabida a condenação em honorários (Súmula 512/STF).

Decorrido o prazo para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça por força de reexame necessário (§1º do art. 14 da Lei 12.016/09).

Servindo a presente como ofício, intime-se o impetrado do inteiro teor desta.

P.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Maricy Maraldi
Juíza de Direito

O presente documento é assinado digitalmente, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.